

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4599/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายเชิด แก้วเขียว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 277, มาตรา 279

จำเลยอุ้มเด็กหญิง ว. ผู้เสียหายอายุ 8 ปีเศษไปนอนบนที่นอนแล้วดึงกางเกงผู้เสียหายรูดลงมาให้เข้าโดยมิได้ถอดออกจากตัวผู้เสียหายและมิได้จับขาผู้เสียหายถ่างออก จำเลยเองก็มิได้ถอดกางเกงของตนออกแต่ได้ล้วงเอาอวัยวะเพศของผู้เสียหายออกมาทางขากางเกงขาสั้นแล้วเอาอวัยวะเพศนั้นจี้ตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหายครั้งเดียวในขณะที่ขาของผู้เสียหายแนบชิดติดกันอยู่ดังนี้ลักษณะการกระทำของจำเลยดังกล่าวยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำชำเราผู้เสียหายได้และจำเลยก็ได้พยายามที่จะเอาอวัยวะเพศของผู้เสียหายใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหาย จำเลยคงมีเจตนาเอาอวัยวะเพศของผู้เสียหายจี้ให้ถูกอวัยวะเพศของผู้เสียหายเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิดเพียงฐานกระทำความอนาจารไม่ผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานกระทำความอนาจารและฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279, 277, 80

จำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำความอนาจาร แต่ปฏิเสธฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารและพยายามข่มขืนกระทำชำเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง และมาตรา 277 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายลงโทษบทหนักตามมาตรา 277 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 จำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง จำคุก 2 ปี ยกฟ้องฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราอีกฐานหนึ่งด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เด็กหญิง ว. ผู้เสียหายมีอายุ 8 ปีเศษ ตามวันเวลาเกิดเหตุ ขณะที่ผู้เสียหายอยู่บนบ้านคนเดียว จำเลยเข้าไปอุ้มผู้เสียหายไปนอนบนที่นอน แล้วจำเลยดึงกางเกงผู้เสียหายรูดลงมาให้เข้าโดยมิได้ดึงออกไปจากตัวผู้เสียหาย จำเลยล้วงอวัยวะเพศของจำเลยออกมาทางขากางเกงซึ่งเป็นกางเกงขาสั้นจำเลยมิได้ถอดหรือดึงกางเกงของจำเลยออก จำเลยนั่งทับตัวผู้เสียหาย ขณะนั้นขาของผู้เสียหายทั้งสองข้างคงแนบชิดกัน จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยซึ่งแข็งตัวจิ้มตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหาย 1 ครั้ง โดยอวัยวะเพศของจำเลยมิได้ล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย พอดีมีเด็กหญิง ส. เดินมา ผู้เสียหายร้องเรียกเด็กหญิง ว. จำเลยจึงลุกขึ้นแล้วรีบเดินออกจากบ้านผู้เสียหายไป ขณะที่จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยจิ้มอวัยวะเพศของผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายไม่สามารถดิ้นรนหลบหนีได้ เพราะจำเลยนั่งทับขาของผู้เสียหายไว้ และขาทั้งสองข้างของผู้เสียหายยังคงแนบชิดกัน คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ได้ความดังกล่าวเป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยดึง

ทางเก่งของผู้เสียหายรุดลงมาถึงเข้าโดยมิได้ถอดออกจากตัวผู้เสียหาย และจำเลยมิได้จับขาของผู้เสียหายถ่างออกขาทั้งสองข้างของผู้เสียหายยังคงแนบชิดติดกัน จำเลยนั่งทับขาของผู้เสียหายแล้วเอาอวัยวะเพศของจำเลยจิ้มตรงอวัยวะเพศของผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวโดยอวัยวะเพศของจำเลยมิได้ล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายเลย ขณะที่เอาอวัยวะเพศของจำเลยจิ้มอวัยวะเพศของผู้เสียหายนั้น ขาของผู้เสียหายยังคงแนบชิดติดกันอยู่ ดังนั้นลักษณะการกระทำของจำเลยดังกล่าวยังไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะกระทำซ้ำเราผู้เสียหายได้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยจิ้มส่วนใดของอวัยวะเพศผู้เสียหาย และจิ้มโดยแรงหรือเพียงแต่จิ้มเบา ๆ ประสงค์จะถูไถทั้งจำเลยมิได้พยายามที่จะเอาอวัยวะเพศของจำเลยใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายแต่อย่างใด จึงเห็นเจตนาของจำเลยได้ว่าจำเลยมีเจตนาเอาอวัยวะเพศของจำเลยจิ้มให้ถูบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายเท่านั้นจึงเป็นเพียงความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง หาเป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำซ้ำเราดังที่โจทก์ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(เสียม ทวีชัยการ-ดุสิต วราโห-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ